

1503036-88.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico varejista, bem como porque, apesar de apreendidos a três ou quatro metros de distância do acusado, houve confissão espontânea na presente data, tendo o increpado confirmado que as porções lhe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503036-88.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503036-88.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Paulo Henrique do Nascimento de Almeida foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 11h50min, na Rua Francisco Ribeiro, 104, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) embalagens contendo 14,8 gramas da droga crack (derivada da cocaína), bem como 32 (trinta e duas) embalagens contendo 25,17 gramas da droga cocaína em pó, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado foi notificado (fls. 120), apresentou defesa prévia (fls. 102/104) e a denúncia foi recebida aos 07 de junho de 2022 (fls. 109/111).

Houve citação (fls. 123).

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da

lei n. 11.343/06, e incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixando-se o regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, no que diz respeito ao desatendimento à determinação judicial para remessa de laudo médico legível, como constou em termo de audiência de custódia, tenho como reprovável a omissão, anotando-se que houve inclusive a reiteração da determinação (fl. 144/145), pelo que determino a intimação pessoal do Sr.

Secretário Municipal de Saúde para que cumpra o determinado e para que oriente aos profissionais médicos para que os laudos em hipóteses semelhantes à presente sejam produzidos de maneira legível.

De todo modo, anoto que, no caso presente, a ausência do laudo médico restou suprida pela vinda aos autos do laudo de exame de corpo de delito encartado às fls. 146/147.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10/11); pelo laudo pericial do local (fls. 73/77); pelos laudos de exame toxicológico (fls. 67/69 e 70/72) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Henrique da Silva disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e avistou o acusado perto de uma moita. Ao notar a viatura, ele tentou deixar o local, mas foi abordado e nada ilícito foi encontrado. Indagada, o acusado disse que estava no local para iniciar a traficância e indicou local onde estavam porções de 'crack' e cocaína, a três ou quatro metros de distância do acusado. Disse que o acusado estava no terreno baldio e, percebendo a viatura, tentou deixar o local. Conhecia o acusado em razão de outras abordagens em pontos conhecidos de venda de drogas. Em nenhuma outra ocasião apreendeu droga com o acusado. Não havia nenhuma outra pessoa na praça. Diligenciou na casa do acusado para obtenção do documento, mas não realizou busca.

Em solo policial, o acusado Paulo Henrique do Nascimento de Almeida disse que estava no local fazendo a venda de substâncias entorpecentes quando acabou sendo abordado por guardas municipais. Disse que estava realizando a venda porque enfrenta dificuldade financeira e precisa do dinheiro para se alimentar (fls. 08). Em juízo, o acusado disse que as porções apreendidas lhe pertenciam e eram destinadas à comercialização. Afirma que praticava o narcotráfico há três meses e recebia R\$ 400,00 por dia. Nada tinha contra os guardas civis que realizaram a abordagem.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico varejista, bem como porque, apesar de apreendidos a três ou quatro metros de distância do acusado, houve confissão espontânea na presente data, tendo o increpado confirmado que as porções lhe pertenciam e eram destinadas à comercialização.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava e mantinha sob depósito quantidade expressiva de drogas diversas acondicionadas de forma fracionada, deve

ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, pois favoráveis as circunstâncias judiciais, estipulando a reprimenda em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local (fls. 73/77) revela que os fatos ocorreram nas imediações de praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no

art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado, na presente data, afirmou que se dedicava ao tráfico de drogas há 3 meses, recebendo R\$ 400,00 por dia dedicado ao comércio espúrio, circunstância que demonstra sua dedicação a atividades criminosas e impossibilita a incidência do redutor postulado pela defesa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do

tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas

apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos

aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial

de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é

incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em

virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição

do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela,

conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o

pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo

regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de

votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a

garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial

fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código

Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza

da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o

regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real

necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da

Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de

reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 – SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Paulo Henrique do Nascimento de Almeida à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Sr. Secretário Municipal de Saúde para que cumpra o determinado em audiência de custódia e para que oriente aos profissionais médicos para que os laudos, em hipóteses semelhantes à presente, sejam produzidos de maneira legível.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 12 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA